

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、誤っているものを2個選びなさい。

1. 甲は、乙が第三者から盗んできた物を、盗品かもしれないと認識していたが、値段が安いのでそれでも構わないと思って有償で譲り受けた。この場合、甲には盗品等有償譲受け罪は成立しない。
2. 甲は、殺意をもって乙の首を絞め、乙が気絶したのを見て既に窒息死したものと誤信し、乙を海に投げ込んだところ、乙は海中で溺死した。この場合、甲には殺人罪が成立する。
3. 甲は、自己が経営する店において、わいせつな映像を録画したDVDを販売したが、あらかじめ同DVDの映像を再生してその内容を認識していたものの、この程度ではわいせつ図画に当たらないと考えていた。この場合、甲にはわいせつ物頒布等罪が成立しない。(改)
4. 甲は、パチンコ店の従業員乙が運搬していた同店の売上金の入ったかばんを強取するため、乙の後方から、乙の頭部を狙い、殺意をもってけん銃の弾丸を発射したところ、同弾丸は乙の肩を貫通した上、甲が認識していなかった通行人丙の腹部に命中し、乙と丙にそれぞれ傷害を負わせた。この場合、甲には、乙に対する強盗殺人未遂罪、丙に対する強盗殺人未遂罪がそれぞれ成立し、両罪は観念的競合となる。
5. 甲は、乙に対して丙に暴行するよう教唆したところ、乙が丙の頭部を1回殴り、その結果、丙が転倒して地面に頭部を打ち付け、脳挫傷により死亡した。この場合、甲には傷害致死罪の教唆犯が成立する。

No.44	事実の錯誤	正答率
共通H23-18	正解 1、3 (順不同)	78%

1 誤っている

最判昭 23.3.16 (百選 I 41 事件)。盗品等に関する罪においては、盗品等であることの認識 (知情) が必要であるが、判例によれば、それは未必的認識で足りるとされている。本記述では、甲は、盗品かもしれないと認識しており、それでも構わないと思っているから、盗品性について未必的認識があるので、「罪を犯す意思」(38 条 1 項本文) がある。よって、本記述では、甲には盗品等有償譲受け罪が成立する。

2 正しい

本記述では、甲は乙の首を絞めて窒息死させる認識でいたところ、現実には乙を海に投げ込んだことにより溺死させている。因果関係の錯誤に関する判例の立場は、犯人の認識した因果の経過と実際の因果の経過との間に食い違い (錯誤) があっても、両者が相当因果関係の範囲内において一致するのであれば、その食い違いは構成要件の評価において重要ではないので、故意を阻却しないというものである。本記述では、甲が認識した乙の首を絞めて窒息死させるという因果関係と、現実生じた乙を海に投げ込んだことにより溺死したという因果関係は、相当因果関係の範囲内で一致するので、殺人罪の故意は阻却されない。よって、本記述では、甲に殺人罪が成立する。

3 誤っている

最大判昭 32.3.13 (百選 I 47 事件) は、わいせつな内容を含む小説の翻訳出版行為について、「刑法 175 条 (現 175 条 1 項、以下同様。) の罪における犯意の成立については問題となる記載の存在の認識とこれを頒布販売することの認識があれば足り、かかる記載のある文書が同条所定の猥褻性を具備するかどうかの認識まで必要としているものでない」とし、理由として、「主観的には刑法 175 条の猥褻文書にあたらないものと信じてある文書を販売しても、それが客観的に猥褻性を有するならば、法律の錯誤として犯意を阻却しない」ということを挙げる。本記述の甲は、あらかじめ DVD の映像を再生してその内容を認識して販売しているので、DVD に録画された映像の存在の認識とこれを頒布販売することの認識があり、わいせつ物頒布等罪の故意は阻却されない。

4 正しい

最判昭 53.7.28 (百選 I 42 事件)。具体的事実の錯誤の問題につき、判例は、A に対する強盗殺人の故意でびょうを発射したものの A を殺害するには至らず、かつそのびょうが通行人 B にも命中したものの B は死亡しなかったという事案において、「犯罪の故意があるとするには、罪となるべき事実の認識を必要とするものであるが、犯人が認識した罪となるべき事実と現実に発生した事実とが必ずしも具体的に一致することを要するものではなく、両者が法定の範囲内において一致することをもって足りる」としつつ、「被告人の右殺人未遂の所為は同巡査に対する強盗の手段として行われたものであるから、強盗との結合犯として、被告人の A に対する所為についてはもちろんのこと、B に対する所為についても強盗殺人未遂罪が成立するというべきである。」としている。よって、本記述では、甲には、乙に対する強盗殺人未遂罪、丙に対する強盗殺人未遂罪がそれぞれ成立し、観念的競合となる。

5 正しい

大判大 13.4.29 は、暴行を教唆したところ、被教唆者が被害者を傷害した結果死亡させた事案において、教唆者も傷害致死の罪責に任ずべきものとしている。よって、本記述では、甲には傷害致死罪の教唆犯が成立する。